Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Antônio da Patrulha

Rua Roberto Xavier da Luz, 06 - Bairro: Cidade Alta - CEP: 95500000 - Fone: (51)3098-5792 - Balcão Virtual: 051.997816408 - Email: frsantantp2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001916-55.2022.8.21.0065/RS

AUTOR: FERNANDA BEATRIZ SEBBEN DA COSTA GOMES

RÉU: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

SENTENÇA

FERNANDA BEATRIZ SEBBEN DA COSTA GOMES ajuizou *ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e pedido indenizatório* contra **SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A**, partes já qualificadas nos autos. Em síntese, narrou ser beneficiária do plano de saúde, Plano Especial 100, código de identificação nº 88888 4559 9800 0025. Aduziu que, no dia 19 de agosto de 2017, foi constatado em exame alterações no Antígeno Carciono embriônico, passando por cirurgia denominada Retossigmoidectomia, em 31/10/2017, para retirada do tumor. Verifica a existência de Metástases de Adenocarcinoma em linfonodos, iniciou-se tratamento quimioterápico e realizados diversos protocolos para o controle da doença, sendo as sessões de quimioterapia realizadas de 15 em 15 dias. Todavia, em 12 de maio, verificou-se através do exame de Tomografia Computadorizada de Tórax em anexo, o aumento dos nódulos pulmonares, fazendo com que fosse necessária a troca do tratamento oncológico. Assim, em 17 de Maio, foi encaminhado o Pedido de Autorização para Quimioterápicos e Adjuvantes requerendo a liberação do seguinte medicamentos de utilização domiciliar via oral: **STIVARGA 40 MG,** o que foi negado pelo plano réu na via administrativa. Aduziu que o custo da medicação em cada sessão de quimioterapia realizada em ciclos de 28 dias importa em R$ 19.460,54, tendo realizado o primeiro pagamento, de R$ 16.566,96, no dia 24 de maio de 2022. Sustentou que o contrato do plano prevê expressamente a cobertura oncológica. Discorreu sobre a legislação pertinente e sustentou que sofreu abalo moral decorrente da negativa, pelo descaso para com a autora. Apontou ter ingressado anteriormente com ações para fornecimento de medicamentos que vinham sendo negado pela parte ré, nº 5001804-57.2020.8.21.0065 e 5003670-66.2021.8.21.0065, com deferimento das tutelas de urgência. Requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que o réu seja obrigado a custear o tratamento junto ao Hospital Moinhos de Vento ou a fornecer o medicamente REGORAFENIBE 40 MG COM VER CT FR PLAS OPC X 84 (15,0 + 6,14) MG a cada 28 dias, iniciando-se em 17 de Junho, sob pena de multa diária. Por fim, postulou a procedência do pedido, para confirmar a tutela de urgência e condenar o réu a restituir os valores pagos pelos medicamentos de forma particular pela autora e a pagar indenização a título de danos morais, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, mas não inferior a 10 (dez) salários mínimos. Juntou documentos.

Na decisão do evento 4.1, restou deferida a tutela de urgência e determina à ré que procedesse no custeio junto ao Hospital Moinhos de Vento e ou fornecesse o medicamente REGORAFENIBE 40 MG COM VER CT FR PLAS OPC X 84 (15,0 + 6,14) MG a cada 28 dias, sendo que o próximo ciclo deve iniciar-se em 17 de Junho próximo vindouro, fixada em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias.

Citado, o requerido apresentou contestação (16.1) impugnando o valor da causa que deve ser o valor de alçada diante do pedido de obrigação de fazer, sem valor econômico. No mérito, aduziu que o medicamento em questão não possui cobertura contratual por não constar no Rol de Procedimentos da ANS para a doença que acomete a autora. Aduziu que não pode ser concedida a cobertura, sob pena de ferir o equilíbrio econômico do contrato. Aduziu que não há comprovação do pagamento do medicamento pela parte autora, a ensejar o pedido de reembolso. Apontou que em eventual reembolso, este deve ocorrer de forma parcial, nos termos do contrato. Impugnou o pedido de danos morais e postulou, por fim, a improcedência da ação. Juntou documentos.

Houve réplica.

Solicitada a realização de Nota Técnica pelo Natjus, houve devolução negativa diante da ausência de profissional na área de oncologia (54.1).

Foi informado o falecimento da autora FERNANDA BEATRIZ SEBBEN DA COSTA GOMES, no dia 14/3/2024, com a solicitação de regularização do polo ativo para o Epólio (63.1).

Encerrada a instrução, a parte ré apresentou memoriais (69.1), assim como a parte autora (71.1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Passo a fundamentar e decidir, atento ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e nos arts. 11 e 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

1. Questão judicial pendente

1.1 Impugnação ao valor da causa

A parte autora traz pedidos cumulados de indenização por danos materiais, para ressarcimento do valor de R$ 16.566,96; por danos morais em, no mínimo, dez salários mínimos (R$ 12.120,00 à época do ajuizamento da ação); além da obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento com pedido de tutela de urgência. Não há na peça portal indicação do tempo previsto para duração do tratamento, apenas indicado o fornecimento a cada 28 dias.

Nos termos do art. 291 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico imediatamente aferível. Ainda, havendo cumulação de pedidos, a quantia deve ser correspondente à soma dos valores de todos eles (art. 292, VI, do CPC).

Desse modo, os pedidos imediatamente auferíveis, no caso em comento, somados os pedidos indenizatórios cumulados, resultam na monta de R$ 28.686,86.

A imprecisão quanto ao tempo do tratamento e o valor econômico do pedido de obrigação de fazer impõe a redução do valor da causa que foi atribuído pela parte autora em R$ 198.803,52. De outra banda, o pleito do impugnante não merece guarida quanto ao pedido de atribuição do valor de alçada, tendo em vista que há conteúdo econômico aferível nos pedidos prefaciais.

Desse modo, acolho parcialmente a impugnação ao valor da causa e retifico o valor da causa para R$ 28.686,86.

2. Mérito

De plano, tem-se que o pedido de obrigação de fazer merece procedência.

Nos termos da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de **plano** de **saúde**, salvo os administrados por entidades de autogestão*."

A autora está acometida de carcinoma de cólon EC IV (CID 10: C18.9), já tendo realizado tratamentos diversos até a indicação de **Regorafenibe 40 mg (nome comercial STIVARGA 40 MG)**, 4 comprimidos 1x ao dia, por 21 dias, pausa de 7 dias, uso contínuo, por tempo indeterminado.

O medicamento está regularmente registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, conforme indicação do médico assistente (1.4). A própria demandada reconhece que o medicamento Regorafenibe 40 mg tem a sua cobertura assistencial vinculada, e indicada pela própria diretriz da ANS, para o tratamento de outras moléstias, mas não para o câncer que acomete a requerente.

A bula do medicamento traz a indicação técnica nos seguintes termos:

> Stivarga® (regorafenibe) é indicado para o tratamento de pacientes adultos com: - tumores estromais gastrintestinais (GIST) metastáticos ou não ressecáveis, que tenham progredido ou experimentaram intolerância ao tratamento prévio com imatinibe e sunitinibe. - carcinoma hepatocelular (CHC) que tenham sido previamente tratados com sorafenibe. - **câncer colorretal (CCR) metastático que tenham sido previamente tratados com, ou não sejam considerados candidatos para, as terapias disponíveis**. Estas incluem quimioterapia à base de fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF e terapia anti-EGFR.

Há nos autos a indicação de outros medicamentos para tratamento da autora, inclusive obtidos diante de ações judiciais pretéritas. Diante da evolução da moléstia, a imprescindibilidade do fármaco no tratamento da doença da parte autora resta comprovada nos autos tanto pelo laudo médico (1.4), como pelos exames realizados antes e depois do início deste tratamento (eventos 1.5 e 44.2).

Tem-se que o uso *off label* não é impeditivo para a cobertura do medicamento, conforme já sedimentou a jurisprudência, destacando-se aresto do Superior Tribunal de Justiça, julgamento do Embargos de Divergência em REsp nº 1.886.929, em 8/6/2022, Ministro Relator Luis Felipe Salomão:

> EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.

1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3º sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4º, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.

2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 quanto do art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas.

3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10-D, § 3º, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar.

4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população.

5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual.

6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo integra a lide. **A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração do Rol.**

7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar.

8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e

para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada.

9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais.

11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS **se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista**; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; **4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS**.

12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos – o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos.

13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado. 14. Embargos de divergência a que se nega provimento.

Cumpre observar, ainda, que a Lei 14.454/2022, ao alterar a Lei dos Planos de Saúde - Lei 9656/98 - para dispor sobre a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados no rol da ANS, definiu que essa lista constitui apenas uma referência básica para os planos, não sendo, de outro modo, limitadoramente taxativa:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***

[...]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, ***constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde*** *contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***

Outrossim, havendo cobertura para a patologia apresentada, conforme se verifica no caso *sub judice*, "*não cabe à operadora de* ***plano*** *de* ***saúde*** *eleger qual o procedimento a que deve ou não se submeter o beneficiário, indicação que cabe exclusivamente ao médico de confiança do paciente*" (AgInt no AREsp 1807169/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

A propósito do uso do medicamento indicado, destacam-se os arestos:

> RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. *PLANO* DE *SAÚDE*. NEOPLASIA MALIGNA DO INTESTINO DELGADO. *MEDICAMENTO REGORAFENIBE* (STIVARGA). TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA. RECONHECIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.(Apelação Cível, Nº 50010683220198210014, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 05-06-2024)
>
> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. *PLANO* DE *SAÚDE*. ADENOCARCINOMA MALIGNO DE CÓLON (CID C18.9 EC IV). *MEDICAMENTO* ANTINEOPLÁSICO. *REGORAFENIBE* 40MG (STIVARGA). *MEDICAMENTO* OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do acórdão que negou provimento ao apelo da re, mantendo, na íntegra, a r. sentença recorrida que julgou procedente a ação, para determinar que a ré forneça ao autor o *medicamento* ***Regorafenibe*** **40mg (Stivarga),** de acordo com a prescrição do *médico* assistente (evento 1, RECEIT9). 2) Os embargos de declaração se constituem como espécie de recurso expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A sua aplicabilidade está delimitada no artigo 1.022 da legislação Processual Civil, o qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua oposição é cabível, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deve se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 3) Nas razões dos declaratórios, a parte embargante apontou omissão no acórdão quanto a previsão legal de exclusão de cobertura para tratamentos off label. Entretanto, essas questões versadas nos aclaratórios foram devida e escorreitamente esclarecidas, debatidas no corpo do acórdão embargado, (transcrição abaixo) razão pela qual, não se trata de obscuridade, contradição ou eventual omissão à luz do art. 1022 do CPC. 4) **"...No caso em comento, o autor foi diagnosticado com adenocarcinoma maligno de colon, patologia classificada sob o CID C18.9 EC IV (fígado e pulmão), com metástase hepática desde agosto de 2019, doença que se encontra em estágio avançada e necessitando com urgência de tratamento oncológico, nos termos do laudo *médico* acostado no evento 1, LAUDO8 A cobertura foi negada pela apelante sob o argumento de que se trata de *medicamento* off - label. ... Ademais, havendo previsão de cobertura no rol da ANS, ainda que para doença diversa, o *médico* assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações de uso daquele específico remédio, tornando inviável que a operadora do *plano* se negue a cobrir o tratamento previsto no rol da ANS, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações de utilização do *medicamento*, considerando que representaria inegável ingerência na ciência *médica*, em prejuízo do paciente enfermo..."** 5) O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. 6) Com efeito, não se verifica a omissão apontada, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição, pelo que, imperiosa a manutenção da decisão embargada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS (Apelação Cível, Nº 50176524820228210022, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 25-04-2024)

Desse modo, devida a cobertura do tratamento proposto pelo médico assistente e após a realização de tratamentos pretéritos e progressivos até à nova indicação, o reembolso pelo pagamento efetuado pela parte autora de forma particular em face da negativa da ré ao tratamento é medida que se impõe.

O pagamento ocorreu no valor de R$ 16.566,96, no dia 24/5/2022, conforme Nota Fiscal constante no evento 1.11, devendo ser o valor atualizado monetariamente pelo IPCA até a citação, com atualização pela taxa SELIC a partir de então, o que já engloba juros e correção monetária, conforme disposto no art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do Código Civil, e art. 240 do Código de Processo Civil.

No que concerne ao dano moral, tem-se que o pedido da parte autora merece guarida.

Observa-se da situação em comento que a demandante, beneficiária do plano de saúde, necessitou reiteradamente recorrer ao poder judiciário para alcançar seu direito ao tratamento do qual necessitava para combate ao câncer diagnosticado em agosto de 2017.

É induvidoso como a doença grave afeta a vida do enfermo, sendo o tratamento do câncer, em si, penoso e assustador. Aliado a isso, o plano de saúde, não obstante duas decisões pretéritas favoráveis à parte autora, que analisaram o caso concreto, a evolução da doença da demandante e a indicação dos médicos assistentes, insistiu no indeferimento de medicamento prescrito sem que apresentasse, em contrapartida e no caso concreto, solução técnica diversa, com evidências científicas, que contrapusesse os laudos médicos até então expedidos e tendo por primazia o tratamento de saúde da paciente e o objetivo de êxito na remissão da doença.

A negativa pura e simples pela ausência de previsão pela ANS quanto às diretrizes de utilização medicamentosa, ignorando o histórico de saúde da paciente e adotando entendimento padrão que, como se viu, se mostrou indevido e abusivo ao caso em comento, desmontara a negligência e descaso da ré para com a beneficiária do plano de saúde.

Desse modo, o temor da parte diante da negativa reiterada dos tratamentos, impondo à parte autora o ajuizamento reiterado de ações judiciais, traduzem o abalo moral suportado pela beneficiária do plano de saúde, agravado diante da gravidade da doença que lhe acometia e da imprescindibilidade e celeridade dos tratamentos prescritos pelo médico assistente para fins de remissão do câncer em estágio IV, quando prescrita essa última medicação.

Há evidente falha na prestação do serviço da parte ré que, tendo-se o caso concreto, ultrapassou a esfera do aceitável e enseja o dever na reparação dos danos morais**.**

O montante deve ser fixado com base no caráter pedagógico e princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as condições do ofensor, do ofendido do contexto dos fatos ocorridos e do bem jurídico lesado. Além disso, devem ser levadas em consideração as condições financeiras das partes.

Assim, a condenação ao pagamento de danos morais é medida impositiva, mostrando-se razoável a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de reparar o dano moral sofrido pela autora, sem possibilitar o enriquecimento sem causa, fixado dentro dos parâmetros acima descritos. O valor da indenização deve ser acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, diante da existência de contrato que vincula as partes. A correção monetária deve ser feita a partir da data do arbitramento da indenização, conforme a súmula 362 do STJ. Dessa forma, nos termos da Lei 14.905/2024, em vigor desde 30/8/2024, no que concerne à alteração do art. 406, caput, do Código Civil, aplica-se a taxa legal SELIC que engloba juros e correção monetária.

Isso posto, confirmo a tutela de urgência (4.1) e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por FERNANDA BEATRIZ SEBBEN DA COSTA GOMES contra SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A para CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente em fornecer à autora o medicamento REGORAFENIBE 40 MG, enquanto foi necessário ao tratamento da moléstia, incluídos eventuais aumentos de dosagem e frequência, conforme prescrição do médico assistente e até a data do falecimento da paciente; e CONDENAR a ré no reembolso do valor de R$ 16.566,96, corrigido pelo IPCA desde o desembolso, no dia 24/5/2022, e atualizado isoladamente pela SELIC a contar da citação, bem assim no pagamento de indenização a título de danos morais, em favor da parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação e atualizada pela SELIC, de forma isolada, deste a prolação desta sentença.

Condeno a ré ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o art. 1.010, §1º, do CPC. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao E. TJ/RS.

Após o transito em julgado, nada mais sendo requerido, baixe-se.

Com o trânsito em julgado, baixe-se o feito no sistema informatizado.

Demais providências:

1. A petição do evento 23 não diz respeito ao feito, intimem-se as procuradoras da parte autora para juntada no feito correspondente, se desejarem, sendo que após 15 dia o documento deve ser excluído deste processo.

Decorrido o prazo, exclua-se o documento.

2. Cumpra-se integralmente o despacho do evento 65.1 para retificação do polo ativo.

3. Retifique-se o valor da causa para R$ 28.686,86.

Documento assinado eletronicamente por **MARCIO LUCIANO ROSSI BARBIERI HOMEM, Juiz de Direito**, em 12/06/2025, às 13:36:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10084407352v41** e o código CRC **13f979fa**.